

<제08장 근로관계의 종료.제03절 해고의 절차적 정당성>

<제09장 비정규근로자.제01절 기간제근로자>

<제15장 부당노동행위.제06절 부당노동행위에 대한 구제>

[기출]11[2011~2]기간제 근로자와 회사가 주장할 수 있는 해고 관련 노동법상 쟁점(해고의 절차 및 구제신청의 이익)

《[문제2] 근로자 甲은 상시근로자 10인이 근무하는 A회사와 2010년 8월 1일부터 2011년 7월 31일까지를 계약기간으로 하는 근로계약을 체결하고 근무해 왔다. 2011년 6월 30일 甲은 대표이사로부터 '직장질서 문란으로 오늘자로 해고한다.'라는 전화를 받았다.

甲은 2011년 7월 20일 관할 지방노동위원회에 (i) 2011년 6월 30일 자 해고가 부당함을 인정할 것, (ii) 원직복직 및 해고기간 동안의 임금상당액을 지급할 것을 내용으로 하는 부당해고 구제신청을 제기하였고, 이에 대해 관할 지방노동위원회는 2011년 8월 30일 심판회의를 개최할 예정이다.

이 사례에서 甲과 A회사가 주장할 수 있는 노동법상 모든 쟁점들을 적시하고 간략하게 설명하시오(직장질서 문란으로 인한 해고의 정당한 이유는 인정되고, 근로계약 갱신에 대한 기대가능성은 없는 것으로 전제한다). (25점)》

<문제2> 기간제 근로자와 회사가 주장할 수 있는 해고 관련 노동법상 쟁점(해고의 절차 및 구제신청의 이익)

I. 문제의 제기

- 사안은 상시근로자 10인이 근무하는 A회사가 기간제 근로자 甲에 대해 해고 당일 전화 해고 통보를 한 상황이다. 쟁점으로 <A회사가 실시한 해고의 실체적 사유의 정당성 여부(사안은 인정)와 절차적 의무가 준수되었는지>, <절차적 의무 중 해고예고의무 위반으로 인한 해고예고수당의 청구가 가능한지>, <부당해고심판 계속 중 계약기간이 만료된 경우 구제신청의 이익이 존재하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 구체적이고 실체적인 쟁점의 쟁점들을 판례의 태도를 바탕으로 설명한다.

II. 해고의 서면통지 의무 위반과 실체적 사유의 경합

1. 근로자 甲의 주장

(1) 서면주의 강행규정 위반

- "근로기준법 제27조"에 의하면 사용자가 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 하며, 서면으로 통지하지 않은 해고는 효력이 없다. 甲은 대표이사가 전화로 단행한 구두 해고 처분이 명백히 서면통지 의무를 위반하여 사법상 무효라고 주장할 것이다.

(2) 실체적 정당성 판단의 불필요성

- 절차적 요건인 서면통지 의무를 위반한 이상, 해고의 실체적 정당성 여부를 불문하고 해당 해고는 법적으로 부당해고로 귀결된다는 점을 강조할 것이다.

2. 사용자 A회사의 주장

(1) 실체적 정당성 강조

- A회사는 전화 통지를 한 경위에 직장질서 문란이라는 근로자의 중대한 귀책사유가 존재했음을 피력할 것이다. 실체적으로 해고할 만한 정당한 이유가 존재하므로 형식적 하자만을 이유로 해고 전체를 부당하다고 보는 것은 불합리하다고 주장할 여지가 있다.

(2) 서면주의 판단에 대한 반박

- A회사는 신속한 인사 조치의 필요성과 구두 통지를 통한 사실의 전달력에 비추어 실질적으로 해고의 사유와 시기가 근로자에게 인지되었으므로 절차적 하자가 치유되었거나 가벼운 하자에 불과하다고 항변할 수 있으나, "판례"의 엄격한 서면주의 태도에 비추어 수용되기는 어렵다.

III. 해고예고의무 위반과 예고수당 청구의 당부

1. 근로자 甲의 주장

(1) 30일 전 예고의무 위반

- "근로기준법 제26조"에 따르면 사용자는 근로자를 해고하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 예고수당으로 지급하여야 한다. 甲은 계속근로기간이 11개월에 달하므로 해고예고 제외 대상이 아니며, 즉시해고를 단행한 A회사를 상대로 예고수당 지급 청구를 주장할 것이다.

(2) 법정 청구권의 확립

- 해고예고를 하지 않은 정황이 명백하므로, 통상임금 30일분 이상의 예고수당 지급 청구권이 당연히 성립한다는 점을 주장할 것이다.

2. 사용자 A회사의 주장

(1) 해고 효과의 무관성 주장

- A회사는 해고예고를 하지 않았거나 예고수당을 지급하지 않았더라도, 이는 근로기준법상 단속규정에 불과하여 해고 자체의 사법상 효력에는 아무런 영향이 없다고 주장할 것이다. 즉, 해고예고의무 위반이 해고를 부당해고로 만드는 사유는 아님을 지적할 것이다.

(2) 구제절차 내 청구의 부적절성 제기

- A회사는 해고예고수당의 지급 청구는 노동위원회의 구제명령 대상이 아니므로, 구제신청 절차 내에서 임금 상당액과 함께 예고수당을 청구하는 甲의 청구 범위는 각하되거나 기각되어야 한다고 방어할 것이다.

IV. 기간 만료에 따른 구제신청의 이익 존부

1. 근로자 甲의 주장

(1) 임금 상당액 지급을 구하는 구제이익 존재

- 甲은 비록 2011. 7. 31.자로 계약기간이 만료되어 원직복직은 불가능하게 되었으나, 부당한 해고 기간(2011. 6. 30. ~ 2011. 7. 31.) 동안 근로를 제공했다면 받을 수 있었던 임금 상당액을 지급받을 필요가 있으므로 구제신청의 이익이 여전히 유지된다고 주장할 것이다.

(2) 판례 변경에 따른 권리 보호

- "대법원 전원합의체 판결"에 의하여 계약기간 만료 등으로 소급 복직이 불가능한 경우에도 해고기간 중의 임금상당액 청구를 위한 구제이익이 인정되므로 노동위원회가 심리를 계속하여 인용 판정을 내려야 한다고 주장할 것이다.

2. 사용자 A회사의 주장

(1) 원직복직 불능에 따른 각하 주장

- A회사는 갱신에 대한 기대가능성이 없는 기간제 근로계약이므로 2011. 7. 31.자로 근로관계가 완전히 당연 종료되었다는 점을 강조할 것이다. 복직 대상인 근로관계가 소멸하였으므로 행정적 구제절차인 구제신청은 대상 소멸로 각하되어야 마땅하다고 주장할 것이다.

(2) 민사적 해결의 원칙 제시

- A회사는 이미 종료된 계약관계에 대하여 임금당상액을 청구하는 것은 사법상의 민사소송을 통해 해결할 성질의 것이며, 행정적 소급 구제 수단인 노동위원회 절차를 유지하는 것은 행정력 낭비에 해당한다고 주장할 것이다.

V. 사안의 적용

1. 해고의 정당성 및 예고의무 판단

- A회사의 해고는 실제적 사유가 인정되더라도 서면통지 요건을 결여한 치명적인 절차 위반이 존재하므로 부당해고임이 명백하다. 甲의 해고예고수당 청구권은 성립하나 이는 민사 소송의 영역에 해당하므로 노동위원회 절차에서는 다루어질 수 없다.

2. 구제신청 이익의 귀속

- 사용자 A회사의 당연종료 및 각하 주장은 종래 판례에 부합하는 면이 있었으나, 변경된 “전원합의체 판례”의 법리에 의하면 근로자 甲에게 해고기간 동안의 임금 상당액 수령을 위한 구제이익이 인정된다. 따라서 구제절차는 각하되지 않으며 임금 상당액 지급 명령의 범위에서 인용되어야 한다.

VI. 결론

- <근로자 甲>은 절차 위반에 따른 해고의 사법상 무효와 “전원합의체 판례”에 근거한 임금 상당액 범위 내의 구제이익 유지를 주장할 수 있으며, 이 주장은 정당하다. 반면, <사용자 A회사>는 계약 만료에 따른 복직 불능을 이유로 구제이익의 소멸(각하)과 해고예고의무 위반이 해고 효력에 영향을 미치지 않음을 주장할 수 있으나, 임금당상액 청구에 관한 구제이익을 인정하는 최근 판례의 확립된 태도에 밀려 각하 주장은 기각될 것이다. 결국 <노동위원회>는 복직 청구는 각하하되 1개월분의 임금 상당액을 지급하라는 명령을 내려야 한다.